

1500772-64.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500772-64.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500772-64.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080709/2022 - 07º D.P. GUARULHOS, 23816232 - 07º D.P.

GUARULHOS, 2080709 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEONARDO ARAUJO OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

LEONARDO ARAUJO OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de março de 2022, por volta das 01h20min, na Rua Pedra Bela, 51, Taboão, nesta cidade e comarca de Guarulhos, trazia consigo, para fins de tráfico, 32 porções de cocaína, com massa líquida de 22,1 gramas e 37 porções de maconha, com massa líquida de 91,3 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação provisória de fls. 16/18 e laudo definitivo de fls. 61/62) (fls. 67/68).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/33 e fls. 58/59).

Devidamente notificado (fls. 90/91), o acusado ofereceu defesa preliminar, com rol de testemunhas (fls. 93/97).

A denúncia foi recebida em 26 de maio de 2022 em audiência (fls. 98/99).

Na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada no dia 26 de maio de 2022, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns: Felipe Nunes dos Santos (PM) e Vinicius de Barros Figueiredo (PM) e as testemunhas de defesa, Alexander Caíque Ferreira, Diego dos Santos, Nájila Alves Francisco e Franciele Batista da Silva. Em seguida, o réu foi interrogado (fls. 98/101). Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado. A respeito do cálculo de pena, a pena-base poderá ser fixada acima do mínimo legal, em razão da diversidade e natureza das drogas localizadas com o réu. Ademais, deve ser considerado, para elevar a pena-base, que o réu praticou o crime durante cumprimento de pena. Incidirá a agravante da reincidência específica. Na terceira fase, inviável o reconhecimento do art. 33, §4º da Lei 11.343. O regime deverá ser o fechado. Em virtude da reincidência e da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Incabível o sursis. A prisão do réu deve ser mantida, diante da reincidência (fls. 99/101).

Em alegações finais, a defesa do acusado requereu a improcedência da ação penal com a absolvição do denunciado, nos termos do art. 386, II, V e VII do CPP. Em caso de condenação, subsidiariamente, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal, que o denunciado possa apelar em liberdade e seja fixado o regime prisional aberto (fls. 102/108).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 1/12), laudo de constatação provisória (fls. 16/18), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 60/62), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de TETRAHIDROCANNABINOL (THC) e COCAÍNA, bem como pela prova oral trazida aos autos. A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado LEONARDO ARAUJO OLIVEIRA, em solo policial, permaneceu em silêncio (fl. 05). Em juízo, negou os fatos. Disse que foi com a esposa no bar comprar cigarro e ficou conversando com amigos. Estava do lado dos meninos na calçada do bar, fumando. Conhece Alexander, mas não Diego, que estava na mesa de sinuca. Sua mulher foi embora. Em questão de dez minutos, passou uma moto em fuga, com dois indivíduos e depois uma viatura. Correu no sentido da viatura, pois se assustou em razão do horário e de suas passagens. Alexander correu para o outro lado, mas não sabe dizer o motivo. Os policiais fizeram o retorno e o alcançaram. Eles pediram a arma e disseram que o interrogando estava de blusa vermelha na garupa da moto. Mencionaram ainda que se ele não estava em fuga, estava traficando, mas não era verdade. Não viu onde a bolsa com as drogas foi encontrada. Foi colocado sentado de frente para o portão de uma casa. Em seguida, um dos policiais voltou com uma bolsa, dizendo que ele havia dispensado. Não conhecia os policiais. Indagado pela defesa, disse que não viu onde foram encontradas as drogas, pois já estava abordado. O dinheiro que guardava estava no bolso de trás de sua calça. Questionado, por fim, acredita que os policiais afirmaram que as drogas eram dele por conta de sua passagem pelo tráfico.

A negativa do réu, contudo, encontra-se isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.

Os policiais militares FELIPE NUNES DOS SANTOS e VINICIUS DE BARROS FIGUEIREDO, em solo policial, em depoimentos semelhantes, narraram que visualizaram uma motocicleta que ao avistar a presença da guarnição passou a acelerar, a saber uma XRE de cor preta, com dois indivíduos, e então a equipe passou a realizar um breve acompanhamento junto a motocicleta; que continuou até o bairro do Jd. Marilena, e pela rua São Sebastião da Boa Vista a motocicleta conseguiu se evadir da guarnição, e pela mesma via, havia alguns indivíduos, os quais não é possível saber se eram

indivíduos que estavam na motocicleta, que correram em desabalada carreira, entre eles um indivíduo do sexo masculino, e já pela rua Pedra Bela, antes de ser alcançado arremessou uma bolsa de cor cinza em direção a calçada. Ato contínuo, equipe abordou o indivíduo, justamente para exaurir a fundada suspeita de se tratar ou não de um dos ocupantes da motocicleta. Durante a busca pessoal a equipe localizou um celular pessoal e a quantia de duzentos reais em diversas notas no bolso direito da parte de trás da calça. Indagado quanto a procedência da quantia e do celular, nada disse a equipe, e que permaneceu no local da abordagem sob a guarda do Sd. Vinicius. Então a equipe retornou ao local próximo da dispensa da bolsa, e por lá localizou a mesma. No interior da bolsa havia objetos análogos a entorpecente e então retornou ao local da abordagem e proferiu voz de prisão em flagrante, e informou os direitos ao indivíduo identificado como Leonardo, maior de idade. Realizou o uso de algema com fundado receio de fuga. Ato contínuo, Leonardo foi conduzido à Delegacia para apresentação ao Delegado de Polícia. Leonardo após ser detido ofereceu a equipe um valor para ser liberado (fls. 02/03 e fl. 04).

Em juízo, o policial militar FELIPE NUNES DOS SANTOS recordou-se do réu de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Estavam em patrulhamento quando foi irradiado no COPOM que tinham duas motos efetuando roubo pela área. Conseguiram realizar o acompanhamento de uma delas. Perseguiram a XRE Preta, com dois ocupantes. O garupa desembarcou e se misturou a populares, cerca de dez pessoas. O condutor da motocicleta continuou guiando. Algumas dessas pessoas correram, dentre elas o réu. Cada uma correu para uma direção. Perseguiu o réu, pois ele correu em direção à viatura. Viu o acusado dispensando uma bolsa cinza, dentro da qual foram encontradas drogas. A mochila do réu foi dispensada em uma travessa da rua principal. Não sabe dizer a quantidade exata de drogas, mas era maconha e cocaína. Em poder do acusado foram localizados celular e dinheiro. Ele não apresentou justificativas. Pessoas se aproximaram dizendo ser parentes do réu, mas não acompanharam a abordagem. A ocorrência se deu por volta de 23h até 01h. Questionado pelo Ministério Público sobre se visualizou o momento exato em que o réu dispensou a sacola ou se a mesma estava na direção em que o réu correu, informou que foi ato contínuo, viu ele dispensando a sacola, tanto que a equipe não o perdeu de vista. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar VINICIUS DE BARROS FIGUEIREDO, o qual, em juízo, recordou-se do réu de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes. Narrou que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento e, via rede rádio, foram informados que era preciso apoio, em virtude de dois indivíduos em uma motocicleta terem se evadido de outra viatura. A moto foi na direção da equipe da testemunha. Iniciou-se uma perseguição e a moto entrou no bairro Maria Helena, onde havia outras pessoas, cerca de quatro a cinco. O réu, que estava de blusa vermelha e na garupa da moto, desembarcou e tentou se evadir a pé. Na Rua Pedra Bela, o réu se desvencilhou de uma bolsa, uma pochete de ombro, jogou-a na rua e continuou correndo. Abordado, foi revistado pelo Cabo Nunes. Ficou na segurança enquanto seu colega retornou ao local onde o réu se desvencilhou da mochila, que continha entorpecentes. A moto continuou no sentido centro-bairro. Visualizou o réu dispensando a pochete. Em poder dele foram encontrados R\$200,00 e celular. A princípio, o réu negou estar na moto e no tráfico. Quando o Cabo Nunes retornou com a pochete, o réu admitiu estar praticando o tráfico. Ele ofereceu dinheiro para ser liberado. Quando o acusado viu as drogas, disse "a casa caiu senhor". O acusado não desbloqueou o aparelho celular. Durante a abordagem, o celular do acusado tocou, atendeu e ficou nítido que ele estava envolvido no tráfico, pois a pessoa perguntou se o "tático" estava lá. O réu se calou. Não conhecia o acusado. Uma mulher se aproximou do local, dizendo ser prima do réu, mas, quando questionada, disse que ele veio de outro Estado e era prima de consideração. Duas moças estavam na via e vieram da rua principal. Acredita que o ocorrido se deu por volta das 01h ou 02h. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

A testemunha de defesa FRANCIELE BATISTA DA SILVA, em juízo, confirmou ser dona do bar. Visualizou o réu chegando com a esposa. Estavam apenas os dois. Logo em seguida, a esposa foi embora. Ele comprou um cigarro solto. Estava de agasalho vermelho e conversava com algumas pessoas. Visualizou uma moto em fuga perseguida por uma viatura da polícia. Não sabe dizer se Leonardo saiu para ver o que estava acontecendo ou para ir embora. Leonardo não estava com nada em mãos, apenas comprou um cigarro solto. Não conhecia muito o acusado. No bar tinham duas pessoas bebendo e dois meninos que o réu conhecia. Não soube dizer o que aconteceu quando a viatura passou. Não soube dizer quem são Alexander e Diego. Não visualizou a abordagem. Não foi a mulher que se aproximou da polícia na ocasião, dizendo ser prima de consideração do réu. Negou conhecer Fernanda. O réu não estava com nenhuma bolsa e pegou o dinheiro do bolso da calça jeans. Não soube dizer se o acusado já se envolveu com o tráfico. Questionada pelo Ministério Público sobre se ela ou alguém do bar avisou Alexander de que o réu havia sido preso, disse não conhecer Alexander.

A informante NAJILA ALVES FRANCISCO, esposa do réu, em juízo, negou ter presenciado a prisão de Leonardo. Foi até o bar comprar um cigarro com o réu porque não fica sozinha em casa. Leonardo encontrou o colega chamado Vinicius e ficou na frente do bar conversando. Foi embora e voltou sozinha para casa. Saiu do local por volta de 01:20h ou 01:25h. Vinicius ligou dizendo que Leonardo tinha sido detido por tráfico de drogas. Negou conhecer Alexander e Diego. Ratificou não ter presenciado a prisão. Apenas quando chegou ao 7º D.P. soube de mais detalhes. Informaram-lhe que o réu foi detido por tráfico de drogas e estava com uma bolsa. Leonardo saiu de casa sem nada. Franciele é a dona do bar. Franciele comentou que Leonardo estava na frente do bar, havia uma moto em fuga, indivíduos correram e Leonardo acabou sendo abordado. Tinha conhecimento das passagens do réu por tráfico e, por isso, não o deixava sair sozinho a noite. Está com Leonardo há mais de um ano e passaram a morar juntos quando ele progrediu para o regime aberto.

A testemunha de defesa DIEGO DOS SANTOS, em juízo, afirmou conhecer o réu de vista do bar que frequentavam. Disse que estava dentro do bar, junto com outros dois homens, cujos nomes ou apelidos não sabe. Desconhece o nome da pessoa que atende no bar. No bar tinham quatro rapazes mais a dona. Estava jogando, quando o réu chegou junto com Alexander. Alexander não estava no bar bebendo antes. Encontrava-se no bar desde às 23h e os acontecimentos se deram por volta da 01h. Leonardo foi comprar um cigarro solto, quando passou uma motocicleta junto com a viatura. Leonardo correu para o lado direito e Alexander para o outro, pois se assustaram. Negou que mais alguém tenha corrido. A esposa do réu ficou parada. Os policiais disseram que o réu estava com drogas. Leonardo estava com uma blusa vermelha, calça e chinelo. Não viu a pochete apreendida. O local da abordagem foi próximo ao bar. Os policiais apareceram com a mochila. Ninguém mais se aproximou. A esposa entrou em pânico, começou a chorar e foi para dentro do bar. Não soube se alguém avisou sobre a prisão. Alexander não apareceu mais. Acompanhou desde a abordagem até o réu ser levado pela viatura. Nenhuma prima do réu compareceu no local. Não conhece Fernanda. Não tem conhecimento do envolvimento do réu com o tráfico. Questionado pelo Ministério Público, disse que Leonardo e Alexander saíram quando a moto passou e a viatura veio logo em seguida. Saíram para ver a motocicleta.

A testemunha de defesa ALEXANDER CAÍQUE FERREIRA DA SILVA REIS, em juízo, afirmou conhecer o réu de vista. Não presenciou a prisão. Estava no bar com David, quando Leonardo entrou sozinho para comprar um cigarro. Escutaram o barulho de viatura e saíram do bar para ver o que estava acontecendo. Uma moto estava sendo perseguida por uma viatura e todo mundo correu porque a viatura achou que eles estavam junto com a motocicleta. Ficou com medo, apesar de não ter passagens. Correu para sua casa, mas não soube para onde Leonardo e o David correram. Depois de dez ou quinze minutos, as pessoas do bar foram até a sua casa avisar que o réu tinha sido abordado pela polícia militar. Eram pessoas desconhecidas, mas sabiam onde o depoente morava por ser do bairro. Não soube dizer o que o réu estava fazendo antes de entrar no bar. Ligou para a cunhada do réu para avisar sobre sua prisão. Visualizou o réu sentado no chão, já algemado. A rua estava vazia. Uma vizinha, Fernanda, se aproximou do local junto com a filha e identificou-se como prima de consideração do réu. Não chegou a ver a pochete com o acusado. No bar estavam o depoente, David e o dono. Conhece o dono do bar. Questionado pelo Ministério Público, disse que conhece o réu de vista, do bar. Tem amizade com a cunhada do réu e o nome dela é Fabiana. Não tinha conhecimento do envolvimento do réu com drogas. Não soube dizer se o réu trabalhava. Indagado pela defesa, disse que a cor da blusa de Leonardo era vermelha. Ratificou que o réu não possuía mochila, sacola ou pochete.

Pois bem, após o término da instrução criminal, vislumbra-se que as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram propriamente a abordagem do réu, de modo que suas declarações não possuem o condão de enfraquecer o robusto acervo probatório existente nos autos, que incrimina sobremaneira o réu.

A mais disso, as testemunhas apresentaram versões completamente distintas e contraditórias quando questionadas a respeito de detalhes da ocorrência. Como se verifica, Alexander mencionou que estava no bar com David, quando o réu entrou. Já a testemunha Diego mencionou que o réu chegou no bar juntamente com Alexander e, ainda, a testemunha Franciele ressaltou que visualizou o réu chegando no bar com sua esposa.

Se isso não bastasse, a testemunha Diego em seu depoimento informou que a esposa de Leonardo presenciou a abordagem tanto que entrou em pânico, começou a chorar e foi para dentro do bar, contradizendo as versões da esposa e do próprio réu.

Aliás, registra-se também várias discrepâncias quanto a comunicação da prisão do réu. Enquanto Alexander afirmou que foi ele quem avisou a família do réu ao ligar para a cunhada dele de nome Fabiana, a testemunha Diego afirmou que a esposa soube do ocorrido porque estava presente no local, sem contar que a esposa Nájila afirmou que Vinícius ligou informando que Leonardo tinha sido detido por tráfico de drogas. Portanto, os depoimentos das testemunhas de defesa apresentaram-se contraditórios e incoerentes fragilizando a possibilidade de serem confiáveis.

Por outro lado, a versão do denunciado, além de absolutamente inverossímil, não

restou confirmada, mas pelo contrário, foi afastada pelos depoimentos harmônicos e seguros dos policiais que afirmaram ter visualizado o acusado dispensando uma bolsa que continha drogas.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave.

Assim, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que LEONARDO trazia consigo os entorpecentes apreendidos, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao tráfico, diante da natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos (32 porções de cocaína, com massa líquida de 22,1 gramas e 37 porções de maconha, com massa líquida de 91,3 gramas), da forma como estavam embalados e separados, das circunstâncias que envolveram a prisão do denunciado, com tentativa de fuga e apreensão de dinheiro.

Vale ressaltar que o fato do réu não estar vendendo entorpecentes no momento da abordagem policial, não desconfigura o delito de tráfico de drogas, eis que o tipo penal é de ação múltipla, configurando o crime aquele que pratica qualquer uma das condutas ali descritas, entre as quais a de trazer consigo o entorpecente destinado ao fornecimento a terceiro, conduta esta imputada ao acusado cuja prova restou incontroversa.

Sobre o assunto abarca a jurisprudência:

“É certo que a comprovação exigida pelos delitos previstos nos artigos 33, “caput” e 28, da Lei de Drogas, não é de fácil constatação, sendo certo que, tal análise deve ter por base as provas extraídas da própria situação fática. Desse modo, para que não se cometam injustiças confundindo usuários com traficantes, para configuração das condutas criminosas previstas na Lei em comento, deverão ser analisadas a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do acusado. Também deve se levar em consideração a forma de acondicionamento da droga”. (Apelação nº 0054000-21.2008.8.26.0114, Rel. Des. Borges Pereira, 16ª Câmara. Direito Criminal).

Em outras palavras, traficante “não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas” (RF 320/237).

De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP “RT” 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito” (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO

DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: "considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente." (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, na primeira fase, verifico que a quantidade de entorpecente apreendido (32 porções de cocaína, com massa líquida de 22,1 gramas e 37 porções de maconha, com massa líquida de 91,3 gramas) não se mostra excessiva a justificar aumento da pena-base, sendo certo que sua condenação anterior será considerada na segunda fase de aplicação das penas. No entanto, observo que o réu teria praticado o presente crime enquanto cumpria pena em regime aberto, anteriormente aplicada, em razão da prática de um delito de tráfico de drogas (fls. 38/40), o que demonstra maior culpabilidade e reprovabilidade da conduta, evidenciando ainda descaso com o ordenamento jurídico e com a punição recebida do Estado.

Cumprе salientar que aqui é reconhecido o desvalor da conduta social do réu que pratica um crime durante o cumprimento de pena. Não se está a valorar a condenação propriamente dita, o que será feito na fase seguinte. Nem se diga, portanto, que há violação ao princípio do ne bis in idem. A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. Na linha da orientação firmada nesta Corte, justifica a exasperação da pena-base a circunstância de o crime ter sido cometido enquanto a ré cumpria pena em regime menos rigoroso.

2. Ademais, "não há falar em bis in idem com a reincidência valorada na segunda fase, relativa ao crime que cumpria pena em regime aberto, haja vista que a reincidência denota reprovação por haver reiterado prática delitiva após o trânsito em julgado de um crime anterior; por outro lado, o cometimento desse crime durante o regime progredido traiu os fins da pena, em especial a ressocialização, motivo pelo qual é devido incremento da pena dosada" (HC n.408.726/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 30/5/2018).

3. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp 1072244/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 24/04/2019).

Assim, nessa primeira fase, diante da circunstância judicial apontada, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase da pena, ausentes circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente, por outro lado, a agravante da reincidência, que foi recepcionada pela Constituição Federal por servir como mecanismo de aplicação do princípio da individualização das penas, pois o réu ostenta condenação definitiva, transitada em julgado, em data anterior aos fatos ora apurados, pelo delito de tráfico de drogas (processo n.º 0000112-23.2017.8.26.0535, da 2ª Vara do Foro Criminal de Guarulhos - processo de execução da pena - n.º 001756995.2017.8.26.0041, da Vara das Execuções Criminais do Foro de Guarulhos, conforme certidão estadual de distribuições criminais de fls. 38/40 e F.A. de fls. 35/37) sendo, portanto, reincidente específico. Assim, acresço as penas de 1/6 (um sexto), fixando-as em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena a serem observadas, razão pela qual torno a reprimenda definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Observo que, em face da reincidência, fica afastada a causa de diminuição de pena tipificada no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06. Não há que se falar em bis in idem mormente porque, para incidência da referida causa de diminuição, faz-se necessário que o réu seja primário, o que não se verifica no caso em análise. Esse é o forte posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO POR OUTRO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE DOIS DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA QUE EXTRAPOLOU À INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. CONSIDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA E TERCEIRA FASES QUE NÃO ENSEJA BIS IN IDEM. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO DETERMINADO EM FUNÇÃO DO MONTANTE DA REPRIMENDA IMPOSTA. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. - A reincidência do paciente constitui óbice suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista não estar preenchido o requisito legal da primariedade. Precedentes. - Ademais, a orientação desta Corte de Justiça é no sentido de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...)” (AgRg no HC 630.337/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (Grifei);

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou

integrarem organização criminosa. 2. In casu, tratando-se de réu reincidente (condenado anteriormente por roubo), é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1509254/AC, STJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020) (Grifei);

“(...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecida a reincidência do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes. (...) 8. Habeas corpus não conhecido”. (STJ HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 15.03.2018, DJe 20.03.2018 g.n.).

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288). Diante da quantidade da pena imposta e reincidência do agente incabível a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em se tratando de delito equiparado a hediondo, o regime inicial para o cumprimento de pena para o acusado é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostrarem adequados para a ressocialização do réu, além de serem incompatíveis com sua reincidência específica, demonstrando dedicação à prática delitiva, evidenciando que a medida de reclusão pretérita não surtiu o devido efeito.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento como requerido pela nobre defesa.

No mais, considerando-se a gravidade do delito cometido pelos réu, o regime de pena imposto por lei, o fato do acusado ser reincidente específico e ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº. 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação. Ainda assim, diante das condições subjetivas e a quantidade de pena aplicada ao acusado faz submergir a necessidade de segregação para resguardar a

ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: "O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional".

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: "Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590). Por fim, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR LEONARDO ARAUJO OLIVEIRA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal.

Não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no local onde estiver preso.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição/apreensão de fls. 11/12) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 11 de agosto de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA